



제53회 민사소송법 2차 해설

안녕하세요. 심영식 변리사입니다.

먼저 무더운 날씨 속에 시험을 치르신 모든 수험생 여러분께 수고의 말씀을 전합니다. 열심히 공부하신 만큼 올해 좋은 결과 있으시길 진심으로 기원하겠습니다.

올해 민사소송법은 작년보다는 전반적으로 다소 어렵게 출제된 것으로 보입니다. 늘 그래왔듯이 기본적인 법리를 물어보는 논점이 많았으나, 판례의 결론을 모르면 풀기 어려운 최신 판례 문제가 다수 나왔고 배점에 비해 써야 할 논점이 많았던 문제가 많았으며, 민사집행법에 관한 내용도 출제된 점을 고려할 때 시험장에서는 그리 쉽지만은 않았을 것 같습니다.

아래 답안은 수험생 여러분의 답답함을 조금이나마 풀어드리고자 제 개인적인 견해를 바탕으로 작성하였습니다. 출제자의 의도와 다소 다를 여지가 있음을 참고하시길 바랍니다.

이미 답안지는 우리 손을 떠나갔습니다. 많은 아쉬움이 남으시겠지만 여러분은 그 동안 정말 그 누구 보다 치열한 하루하루를 보내셨습니다. 저 또한 경험자로서, 발표를 기다리는 시간이 마냥 편하지 않은 것을 알지만 시험 생각은 잠시 접어두시고 발표 전까지 꼭 쉬시면서 그 동안 하지 못했던 일들을 하시면서 재충전을 하시길 바랍니다.

다시 한 번 그 동안 너무 고생 많으셨고 아무쪼록 11월에 좋은 결과가 있기를 진심으로 기원하겠습니다.

【 문제-1 】 (30점)

甲이 乙을 상대로 자신의 대여금채권(A채권)을 행사하는 청구와 제3채무자 丙을 상대로 위 A채권을 피보전채권으로 하여 乙의 丙에 대한 매매대금채권(B채권)을 대위행사하는 청구를 병합하는 소를 제기하면서, 乙과 丙이 부진정 연대채무관계에 있음을 전제로 乙, 丙에 대하여 연대하여(각자) 지급할 것을 구하였다. 그런데 법원은 乙과 丙이 부진정 연대채무관계에 있지 않다는 이유로 “乙은 A채권에 관하여, 丙은 B채권에 관하여 甲에게 각 지급하라”고 판결하였다. (다음 각 설문은 독립적임)

- (1) 법원이 위와 같이 개별적인 지급책임을 인정한 것은 적법한지 설명하시오. (10점)
- (2) 소장 접수 후 그 소장부분 송달 전에 乙이 사망하였고, 乙의 단독상속인 丁이 그 소장부분을 송달받고서도 응소하지 않음으로써 청구인용 판결이 선고되었는데, 丁이 그 판결정본을 송달받고서 2주 내에 소송수계신청과 동시에 항소를 제기하였다면 위 소송수계신청 및 항소는 적법한지 설명하시오. (10점)
- (3) 甲이 위 소송에서 丙을 상대로 “丙은 甲에게 1억 원을 지급하라”고 청구하여 전부승소 판결을 선고받아 그 판결이 확정되었다면, 乙은 그 판결을 집행권원으로 하여 丙의 재산에 대하여 강제집행을 할 수 있는지 설명하시오. (10점)



<문제 1>

I. 채권자대위소송 법적성질

II. 설문 1

1. 문제의 소재
2. 처분권주의 의의 및 취지(제203조)
3. 처분권주의 내용
4. 심판대상
 - (1) 일부인용 판결 가부
 - (2) 판례의 입장(2014.7.10, 2012다89832)
 - 개별적 지급책임을 인정한 원심판결은 처분권주의 위반
 - (3) 검토
 - (4) 사안 - 처분권주의 위반
5. 설문의 해결

III. 설문 2

1. 문제의 소재
2. 소송계속의 판단 기준
3. 소제기 후 소장부분 송달 전 사망시 취급
 - (1) 학설 대립
 - (2) 판례(2015.1.29, 2014다34041)
 - 제소전 사망과 동일 취급
 - (3) 검토
4. 당사자 확정
 - (1) 당사자 확정 의의
 - (2) 학설의 대립 - 의사설 / 행동설 / 표시설
 - (3) 판례 - 표시설
 - (4) 검토 및 사안 - 표시설
5. 제소전 사망을 간과한 판결의 효력 - 무효
6. 제소전 사망을 간과한 판결의 상소 가부
 - (1) 학설(긍정) 및 판례(부정)
 - (2) 사안의 판례 - 부정
 - (3) 검토 및 사안 - 항소 및 수계신청 부적법
7. 설문의 해결



IV. 설문 3

1. 문제의 소재

2. 기관력 저촉 여부

(1) 의의 및 취지

(2) 주관적 범위

① 원칙(제218조1항)

② 예외 - 권리귀속주체(제218조3항)

3. 채권자의 판결이 채무자에게 미치는지 여부

(1) 학설의 대립 - 긍정설 / 부정설 / 절충설

(2) 판례 - 절충설

(3) 검토 - 절충설

(4) 사안 - 채무자에게도 소를 제기하였으므로 소 제기 사실 알 수 있음

4. 제3채무자에게 집행가능한지 여부

(1) 원칙 - 기관력의 범위와 집행력의 범위는 동일

(2) 판례의 입장(1979.8.10, 79마232)

- 집행력은 원피고 사이에만 발생, 원고와 채무자 사이에는 발생 X

(3) 검토 및 사안

5. 설문의 해결



【 문제-2 】 (20점)

甲은 우연히 알게 된 국립대학교 교수 乙의 차에 동승하게 되었다. 그런데 乙의 과실로 교통사고를 당하여 큰 부상을 입게 되었다. 甲은 乙을 상대로 불법행위에 기한 손해배상청구의 소를 제기하고자 한다. 乙은 주된 직업이 교수인데 甲은 乙의 주소를 알지 못하여 예전에 乙로부터 받은 명함에서 乙이 사외이사로 되어있는 회사의 본점 소재지를 발견하고서 그곳을 피고의 주소지로 기재하여 소를 제기하였고, 그 회사의 경비원 A는 乙이 상근하지 않음에도 불구하고 소장 부분 및 변론기일통지서를 송달받았다. 그 결과 법원은 답변서 부제출을 이유로 乙이 청구원인사실에 대해 자백한 것으로 보고 청구인용 판결을 선고하였다. (다음 각 설문은 독립적임)

(1) 위 각 송달 및 판결은 유효한지 설명하시오. (10점)

(2) 위 판결정본이 위와 동일한 방법으로 송달되어 2주가 경과되었다면 乙이 위 판결에 대하여 항소를 제기하여 위 청구원인사실에 대한 자백의 효력을 다룰 수 있는지 설명하시오. (10점)



<문제 2>

I. 설문 1

1. 문제의 소재

2. 송달 적법여부

(1) 의의

(2) 송달받을 사람

(3) 송달실시 방법

① 교부송달(제178조) 및 보충송달

② 송달할 장소(제183조) - 주소, 영업소(제1항) / 근무장소(제2항)

③ 판례(2015.12.10, 2012다16063)

- 사외이사의 직을 갖고 있는 사람에 대한 그 회사의 본점은 근무장소 X

④ 사안 - 근무장소가 아니므로 원칙적으로 송달 무효

3. 이의권 상실 여부

(1) 의의 및 취지

(2) 이의권 대상 - 통상의 서류

(3) 사안 - 송달 유효해짐

4. 판결의 적법여부

(1) 자백간주 의의 및 요건

(2) 사안 - 송달 유효해졌으므로 판결은 적법

5. 설문의 해결

III. 설문 2

1. 문제의 소재

2. 송달 적법 여부 - 무효

3. 이의권 상실 여부

- 판결정본은 이의권 상실 대상X (통설 및 판례)

4. 항소 제기 가부 - 항소 기간 진행되지 않았으므로 항소 제기 가능

5. 자백간주 효력 번복 여부

(1) 의의 및 취지

(2) 요건 및 사안

(3) 효력 - 당사자에 대한 구속력은 없으므로 항소로 다룰 수 있음

6. 설문의 해결



【 문제-3 】 (30점)

甲과 乙은 동업을하기로 계약을 맺은 후, 동업자금의 조달을 위하여 丙에게 “동업을 위한 자금이 필요하다.”고 말하고서 丙으로부터 1억 원을 차용하였다.
[아래 (1), (2) 설문 상호간, 가., 나. 설문 상호간은 각 독립적임]

(1) 丙이 甲을 단독피고로 하여 위 대여금 전액의 반환을 구하는 소를 제기하여 제1심에서 전부승소 판결을 선고받았는데, 甲이 항소를 제기하여 그 변론기일에 “乙과의 동업자금으로 차용한 것이므로 甲에게만 청구한 것은 부적법하다.”는 주장을 하였다.

가. 甲의 위 주장사실과 관련된 소의 부적법 사유가 항소심에서 치유될 수 있는 방법이 무엇인지 설명하시오. (10점)

나. 丙이 항소심 도중 위 소를 취하하고 나서 甲, 乙을 공동피고로 위 대여금 1억 원의 반환을 구하는 새로운 소를 제기하였다. 이에 甲이 “소를 취하하고서 같은 소를 다시 제기하는 것은 부적법하다.”고 주장하였다면 법원은 이 주장에 관하여 어떻게 판단하여야 할 것인지 설명하시오. (10점)

<문제 3>

1. 설문 1

1. 문제의 소재

2. 소송수행 형태

(1) 종류

(2) 사안 - 동업약정 -> 준합유 -> 고필공

3. 소 적법 여부

(1) 고필공 소송요건 - 전원 당사자

(2) 사안 - 부적법

4. 보정 방법

(1) 별소제기 후 변론병합 - 심급의 이익을 해치므로 X

(2) 고필공 추가 가부(제68조)



- ① 의의 및 취지
 - ② 요건 및 사안 - 1심에서만 가능하므로 사안의 경우 불가
 - (3) 乙의 공동소송 참가 가능 여부
 - ① 학설 대립 - 긍정 / 부정
 - ② 검토 및 사안 - 긍정설
5. 설문의 해결

II. 설문 2

- 1. 문제의 소재
 - 2. 재소금지 저촉 여부
 - (1) 의의 및 취지
 - (2) 요건 - 권리보호 이익의 문제
 - (3) 권리보호 이익 인정 여부
 - ① 의의 및 취지
 - ② 판단기준
 - ③ 판례 - 재소금지 효력 받지 않음(1957. 12. 5. 4290민상503)
 - ④ 사안 - 전소판결을 농락하려는 의도 X, 당사자 권리구제 위해 인정
3. 설문의 해결

III. 설문 3.

- 1. 문제의 소재
 - 2. 확인의 이익 여부
 - (1) 의의
 - (2) 학설(부정) 및 판례(긍정)의 입장
 - (3) 검토 및 사안
3. 제 3자 반소 적법 여부
- (1) 반소 의의 및 종류
 - (2) 제 3자 반소 가부
 - ① 판례의 입장
 - ② 검토 및 사안
- (3) 제 3자 반소 요건
- ① 판례의 입장(제68조 요건)
 - ② 검토 및 사안
4. 설문의 해결



【 문제-4 】 (20점)

원고는 B청구가 일부청구임을 명시하지 아니한 채 A, B 청구를 병합한 소를 제기하였는데, 제1심 법원은 A청구를 전부 기각, B청구를 전부 인용하는 하나의 판결을 선고하였다. [아래 (1), (2) 설문 상호간, 가., 나. 설문 상호간은 각 독립적임]

(1) 피고는 항소를 제기하지 아니하였는데, 원고가 B청구의 청구취지를 확장하는 신청과 함께 항소를 제기하였다면 그 항소는 적법한지 설명하십시오. (6점)

(2) 위 판결에 대하여 피고만이 항소를 제기하였다.

가. 원고는 항소심에서 B청구의 청구취지를 확장할 수 있는지 설명하십시오. (6점)

나. 원고가 소제기 당시 A청구를 주위적으로, B청구를 예비적으로 심판하여 달라고 심판의 순서를 붙여서 청구하였는데, 항소심 법원이 심리한 결과 A청구가 이유 있고 B청구는 이유 없다고 판단된다면 어떻게 판결하여야 할 것인지 설명하십시오. (8점)

<문제 4>

I. 설문 1

1. 문제의 소재

2. 상소불가분원칙 - B 청구도 이심됨

3. 항소 요건 - 상소 이익이 문제됨

4. 상소의 이익 인정여부

(1) 의의 및 취지

(2) 학설 - 형식적 / 실질적 / 절충설 / 신실질적

(3) 판례 - ① 원칙 - 형식적

② 예외 - 묵시적 일부청구

(4) 검토 및 사안

- 예외적 입장에 따라 청구취지 확장을 위한 항소 가능

4. 설문의 해결



II. 설문 2의 (가)

1. 문제의 소재
2. 항소심 이심 여부 - 상소불가분원칙
3. 부대항소 가능 여부
 - (1) 의의 및 취지
 - (2) 부대항소의 성질
 - (3) 요건
 - (4) 사안 - 부대항소 가능
4. 설문의 해결

III. 설문 2의 (나)

1. 문제의 소재
2. 주위적 청구 심판대상 여부
 - (1) 진정예비적 병합인 경우
 - ① 학설의 대립
 - 심판설 / 비심판설
 - ② 판례의 태도
 - 비심판설
 - ③ 검토 및 사안
 - 비심판설
 - 예비적 청구 부분만 취소 + B청구 기각
 - (2) 선택적 병합의 성질을 갖는 부진정예비적 병합인 경우
 - ① 판례(2014.5.29 , 2013다96868)
 - 주위적, 예비적 청구 모두 심판 대상
 - ② 사안
 - 원판결 취소 + 주위적청구 인용, 예비적 청구 기각
 - (3) 단순 병합 성질을 갖는 부진정예비적 병합인 경우
 - ① 모두 이심이 되나 단순병합 특성상 항소한 예비적 청구 부부만 심판대상
 - ② 사안
 - 예비적 청구 부분만 취소 + B 청구기각
3. 설문의 해결